

1501935-41.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso." (grifo meu).

Aliás, em decisão recente, a Ministra Rosa Weber, assentou que "A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado" (STF, Agravo Regimental no Recurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-400

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501935-41.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501935-41.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATAN LUIS ASSIS DA COSTA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Vistos.

THALES ALECKSANDER FERREIRA MENDES e NATAN LUIS ASSIS DA COSTA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o art. 29 do Código Penal porque, segundo narra a denúncia, no dia 23 de dezembro de 2021, por volta das 12 horas, na Rua João Perossi, 2576, Eldorado Parte 1, nesta cidade e comarca, os acusados, em conluio e unidade de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito e traziam consigo, para fins de comercialização a terceiros, 15 porções de maconha, pesando 174 gramas, substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física e psíquica, listadas na Portaria nº 344/98 do SUS/MS.

Narra a denúncia que policiais, durante patrulhamento pelo local dos fatos, visualizaram, dentro de uma residência, um indivíduo mexendo em uma motocicleta tipo Honda/Biz, cor vermelha, sendo do conhecimento dos policiais que nas proximidades havia duas motocicletas tipo Honda/Biz vermelhas que eram produtos de furto, motivo pelo qual os policiais efetuaram a abordagem, oportunidade em que Natan correu para o fundo da residência carregando uma sacola plástica de cor amarela, sendo acompanhado pelos policiais. Natan jogou a sacola e um telefone celular sobre o telhado da residência (nos fundos do imóvel) e, indagado acerca do que havia no interior da sacola, Natan confessou que havia drogas e que se assustou quando viu os policiais. Assim, os policiais realizaram a busca no telhado da residência e encontraram a sacola contendo 14 pedaços de maconha e um aparelho celular da marca Motorola. Em busca pessoal foi encontrado com Natan um pedaço de maconha no bolso, além da quantia de R\$ 155,00, em espécie. No interior da residência havia mais um indivíduo, posteriormente identificado como Thales Alescksander Ferreira Mendes e em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, em pesquisa, foi encontrado um mandado de prisão em seu desfavor. Narra que a abordagem e a busca domiciliar foram acompanhadas pela moradora do imóvel Thaciane Ferreira Mendes. Narra que os acusados compartilhavam a posse e propriedade das drogas encontradas e realizavam o tráfico de entorpecentes conjuntamente.

Notificados (fls. 131 e 133), os acusados apresentaram resposta à acusação (fl. 136). Recebida a denúncia (fls. 139/141), os réus foram citados (fls. 192 e 194).

Durante a instrução, depois de ouvidas as testemunhas, os acusados foram interrogados (fls. 222/225 e 274/280).

A instrução foi encerrada e em alegações finais o Ministério Público reiterou o pedido condenatório contido na denúncia, ao passo que as Defesas sustentaram a absolvição, alegando, em suma, falta de provas e ainda alegaram preliminares (fls. 283/290, 294/303 e 305/326).

É o relatório.

DECIDO.

Na fase policial o acusado THALES negou a prática delitiva, afirmando que comprou 10 "pedaços" de maconha para uso próprio pelo valor de R\$300,00, guardando em um armário da casa. Na data dos fatos acordou com barulho dos policiais, que reviravam o imóvel procurando entorpecentes. Negou qualquer envolvimento de Natan. Interrogado em Juízo, o acusado manteve sua narrativa, afirmando que a droga apreendida lhe pertencia, mas se destinava apenas ao consumo. Juntou dinheiro com a irmã e uma amiga dela para comprar a droga para consumo deles e assim evitar ir à "biqueira". Natan estava no local apenas para ficar com a colega de sua irmã. Foi acordado pelos policiais. Trabalhava em um lava-jato. Havia uma moto no quintal da casa, pertencente a uma amiga. Afirmou que possuía um cachorro e o portão da casa ficava sempre fechado. Confirmou que havia mandado de prisão expedido em seu desfavor, condenado pela prática de tráfico de drogas. O corréu Natan não tinha conhecimento da droga e não o conhecia, nem eram amigos. A droga estava no armário da cozinha.

Na fase policial o acusado NATAN asseverou que estava na casa de seu conhecido Thales quando os policiais chegaram e entraram, localizando uma quantidade de maconha que estava no interior do imóvel. Negou qualquer envolvimento com as drogas, relatando que lá estava porque há algum tempo estava "ficando" com Raíssa, irmã de Thales, que também mora no local. Interrogado em Juízo novamente negou a prática do crime que lhe é imputado, dizendo que havia acabado de chegar naquela casa para "ficar" com Raiane, amiga da irmã do corréu. Estava na sala junto com Raiane e o corréu Thales conversando quando os policiais lá ingressaram e passaram

a revirar tudo. Encontraram droga e passaram a acusá-lo, levando-o para a viatura. Negou qualquer envolvimento com as drogas, afirmando que portava apenas um celular e a quantia de R\$155,00, fruto de seu trabalho em uma fábrica de cordas. Confirmou que havia uma motocicleta no imóvel, mas os policiais nada perguntaram sobre o veículo. Frisou que o portão da residência estava fechado, inclusive havia um cachorro no imóvel. Assumiu ser usuário de drogas, mas negou que estivesse com drogas naquele dia. Sobre as imagens extraídas de seu celular disse que costumava compartilhar com amigos, também usuários. O policial lhe disse que tinha o direito de permanecer calado. Ao chegar na delegacia narrou o ocorrido, mas não assinou nenhum documento.

O policial Wellington Oliveira Ferreira ratificou sua narrativa anterior, afirmando que durante patrulhamento visualizaram dentro de uma casa um indivíduo mexendo em uma motocicleta tipo Honda/Biz cor vermelha, sendo que havia notícia de que havia duas motocicletas semelhantes produtos de furto, motivo pelo qual efetuaram a abordagem, mas quando desembarcaram da viatura e se identificaram o indivíduo correu para os fundos da residência carregando uma sacola plástica de cor amarela, sendo acompanhado, quando então ele jogou a sacola e um telefone celular sobre o telhado da residência. Feita a abordagem, o indivíduo foi identificado como sendo o acusado Natan e indagado sobre o que havia no interior da sacola confessou que havia drogas, justificando que se assustou quando viu os policiais. Realizaram busca no telhado da residência e encontraram a sacola contendo 14 pedaços de maconha e um aparelho celular da marca Motorola. Com Natan apreenderam um pedaço de maconha no bolso do short e a quantia de R\$155,00. No interior da residência havia mais um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o acusado Thales e em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas durante pesquisa constatarem que contra ele havia um mandado de prisão. Indicou que a busca domiciliar foi acompanhada pela moradora Thaciane Ferreira Mendes e o portão da residência estava aberto. Natan assumiu a propriedade da droga.

No mesmo sentido é a narrativa do policial Jean Cássio Bocato Marques, confirmando que patrulhavam já com a informação do furto de duas motos de cor vermelha. Passando pelo local avistaram moto semelhante, havendo um indivíduo atrás dela, sendo que a moto estava na garagem da residência, contudo, ao descender da viatura tal indivíduo empreendeu fuga, correndo até os fundos da casa, mas foi seguido, quando avistaram o momento em que ele arremessou a sacola que portava sobre o telhado. Esclareceu que o portão da casa estava apenas encostado. O indivíduo foi identificado como sendo o acusado Natan, o qual assumiu a propriedade da droga. No interior da casa abordaram o acusado Thales e feita pesquisa constatarem que era procurado pela justiça. Não encontraram nenhuma irregularidade com relação à motocicleta.

Ante o exposto, pela prova do feito, angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de rigor a condenação.

A materialidade é comprovada pelos documentos de fls. 9/12 (boletim de ocorrência), fls. 15/16 (auto de exibição e apreensão), fls. 37/39 (fotos da droga), fls.117/119 (exame químico-toxicológico), fl. 259/263 (laudo pericial) e pela prova oral.

De igual forma a autoria restou comprovada, recaindo na pessoa dos acusados, mormente porque a prova dos autos demonstra que de fato atuavam no narcotráfico. Ademais, os policiais foram taxativos em afirmar que apenas efetuaram a abordagem porque suspeitaram da origem da motocicleta e quando se aproximaram o corréu Natan empreendeu fuga, sendo que durante a perseguição ele arremessou a sacola contendo drogas sobre o telhado. O corréu Thales estava no interior da casa.

Embora o corréu Thales assumia sozinha a propriedade da droga, isentando o corréu Natan de qualquer participação, as versões apresentadas não se sustentam nem entre eles. Natan disse que estava na sala com Raiane e Thales e este por sua vez disse

que estava dormindo no quarto. Na fase policial Natan disse que namorava Raíssa, irmã do corréu e em Juízo disse que estava no local para “ficar” com uma amiga dela, que sequer foi arrolada como testemunha para confirmar sua versão. Na polícia ainda disseram que eram amigos e em Juízo negam tal amizade.

Temos ainda as diversas imagens de fls. 262, todas de entorpecentes, extraídas do celular de Natan. Note-se que em algumas delas há grande quantidade de drogas, afastando sua alegação de que tais fotos eram de drogas de seu uso que enviava para amigos também usuários.

Ademais, o acusado Natan empreendeu fuga. Ora, caso não tivesse envolvimento com o ilícito, não teria motivos para fugir.

Vale ressaltar a importância de se aferir o modo de vida dos acusados, no caso, não tendo sido trazidos aos autos elementos que conduzam à certeza quanto à possibilidade de poder incursionar pela seara do uso de drogas. Ademais, não restou comprovada a origem lícita do numerário apreendido.

Além do mais, pode coexistir, na mesma pessoa, a figura de traficante e usuário. O fato de serem usuários de substância entorpecente não obsta ao reconhecimento da figura de traficante. Ao contrário, é natural que ambas as condições, a de usuário e a de traficante coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilitar-se-á o emprego na compra, para que o vício possa ser sustentado.

Quanto ao valor dos depoimentos de policiais, como são servidores públicos, fielmente compromissados com o bem e a defesa da coletividade (o dever funcional de um policial, em sentido estrito, é prevenir e reprimir o crime), presume-se que agem corretamente e são dignos de credibilidade, mormente porque não há nos autos nenhuma notícia de que teriam motivo para imputar acusação falsa aos réus, que sequer conheciam.

Aliás, como já se decidiu, “Os depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o réu, por tráfico ilícito de entorpecentes, gozam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam as provas testemunhais. Apenas porque são policiais não estão não impedidos de depor, tampouco possuem tais depoimentos pequeno valor, sobretudo se os mesmos estão em harmonia com as demais provas dos autos, inclusive com a delação dos usuários da fase inquisitorial” (TJ-DF, Ap. 20030110632367APR, 1ª T., Rel. Edson Alfredo Smaniotto, 09.03.2006, v.u., DJ 31.05.2006, p. 180).

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada” (STJ, HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j.

03/02/2004, DJ 08.03.2004, p. 304).

“Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 – Materialidade delitiva e autoria demonstradas. A forma como ocorreu a apreensão impede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei. Prova - Palavras de Servidores Públicos – Validade - Inexistência de motivos para incriminarem o réu injustamente. Penas fixadas acima do mínimo legal, em razão da reincidência. Regime prisional fechado. Recurso provido” (TJ-SP, Apelação nº 0010112-19.2016.8.26.0050, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Machado de Andrade, v.u., j. 5 de julho de 2018).

Vale ressaltar ainda que para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes basta a ocorrência de um dos verbos do tipo penal (descrição da lei), o que, neste caso, constitui o fato dos réus armazenarem os entorpecentes apreendidos, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Quanto à alegada violação do domicílio, ressalto que o crime de tráfico de drogas é permanente, logo, possível o ingresso em residência, quando existirem indícios da prática de crime. Muito embora a Constituição Federal em seu artigo 5º, XI, diga ser o lar asilo inviolável, essa norma traz exceções, como na hipótese de prisão em flagrante delito, o que se verificou nesse caso. Ademais, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar em 05/11/2015 o Recurso Extraordinário nº 603.616, representativo da controvérsia, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, dotado de repercussão geral, firmou a seguinte tese:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (grifo meu).

Aliás, em decisão recente, a Ministra Rosa Weber, assentou que “A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de

flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado" (STF, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 213.852/RJ, 1ª Turma, j. 30 de maio de 2022).

Ademais, neste caso havia fundadas suspeitas. Havia notícias de furto de motos semelhante àquela que havia no imóvel e o acusado Natan, ao visualizar os policiais, empreendeu fuga dispensando a sacola que continha as drogas.

Por fim, no tocante ao direito ao silêncio o "Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo. (...) Deve se ter em consideração igualmente que a garantia constitucional de não produzir provas contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (nemo tenetur se detegere), 'não pode ser interpretada no sentido de se vedar a produção de qualquer tipo de prova sem a concordância do acusado. Entendimento contrário implicaria o reconhecimento da impossibilidade de se realizar, sem o consentimento do réu, a revista pessoal, o reconhecimento de pessoas, a interceptação telefônica, etc'" (RHC 61.754/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/10/2016, DJe 07/11/2016).

Assim sendo, neste caso, eventual falta de advertência do direito de permanecer em silêncio não acarretou nulidade, muito menos prejuízo à defesa, uma vez a confissão sem a referida advertência teria ocorrido no momento da abordagem policial. Aliás, o réu afirmou que foi advertido de seus direitos constitucionais. Ademais, tanto na delegacia como em Juízo negou prática do crime que lhe é imputado.

Nesse contexto, comprovadas a autoria e materialidade, de rigor a condenação.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atendendo aos critérios do art. 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base no piso, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo a unidade.

Na segunda fase incide a atenuante da menoridade (THALES), contudo, como a pena já está no piso, deixo de aplicá-la (Súmula 231 do STJ - "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"). Quanto ao corréu NATAN não há agravante ou atenuante para ser considerada, permanecendo a pena lançada acima.

Na terceira fase descabida a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos legais: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosas.

Ora, neste caso, embora os acusados sejam primários, sem antecedentes criminais e não havendo notícia de que integre organização criminosas, pode se afirmar que se dedicam a atividades delituosas.

A doutrina e a jurisprudência apontam situações caracterizadoras de atividades criminosas, tais como o fato de o agente estar respondendo a outros processos criminais, encontrar-se na posse de armas e apetrechos relacionados ao tráfico, como embalagens para porções individualizadas, balanças de precisão ou, ainda, quantidade e variedade de drogas apreendidas.

Com efeito, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é destinada somente para os pequenos e iniciantes traficantes, o que não é o caso. Os acusados respondem a outro processo por tráfico de drogas, tendo o corréu Natan já sido

condenado (fls. 52 e 54), não se olvidando que o corréu Thales também teve diversos processos por ato infracional quando adolescente (fls. 63/64). Ressalto que os referidos processos não são maus antecedentes, nem reincidência, mas constatação do envolvimento dos réus com o tráfico de drogas e atividades ilícitas, tudo a confirmar que eles não eram iniciantes na mercancia ilícita.

Nesse sentido decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ERESP N. 1.431.091/SP, TERCEIRA SEÇÃO, DJE 1º/2/2017. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. ART. 65, I, DO CP. APLICAÇÃO DO REDUTOR. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 44, I, DO CP.

1. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem entendido que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (EResp n. 1.431.091/SP, Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 1º/2/2017).

2. Não obstante o agravado não ostentar condenação apta a caracterizar a reincidência, a constatação de que ele está respondendo a outro processo criminal já é fundamento idôneo e suficiente para obstar a concessão do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

3. Preserva-se a decisão monocrática quanto ao entendimento acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ.

4. O pedido subsidiário constante do recurso especial, atinente à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, julgado prejudicado na decisão agravada, nesta oportunidade é passível de análise, haja vista o desprovemento do pleito relativo à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Levando em consideração a reprimenda final definida no combatido aresto (5 anos de reclusão, mais pagamento de 500 dias-multa - fl. 259), verifica-se o não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.

5. Agravo regimental provido, a fim de reconsiderar a decisão agravada, para, com fundamento no art. 255, § 4º, I e II, do RISTJ, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento” (AgRg no REsp 1761672/BA, Rel. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07/05/2019, DJe 20/05/2019, grifo meu).

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, ficam definitivas as penas.

Fixo o regime inicial para o cumprimento da pena de prisão no fechado. Anoto que foram surpreendidos com quantidade considerável de drogas, divididas em porções e embaladas, de sorte que a gravidade concreta do delito se revela totalmente incompatível com regimes menos gravosos. Ademais, respondem a outros processos por tráfico de drogas, a demonstrar a necessidade do regime mais gravoso.

Ressalto que a fixação do regime fechado se faz necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos desta natureza e acautelar o meio social.

Os réus estão presos. Nego o direito ao recurso em liberdade. O crime que cometeram e a pena a que estão submetidos, nesta sentença, são suficientes para retratar suas periculosidades se soltos, de modo que a prisão se sustenta na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ademais, como permaneceram presos durante a

tramitação do processo, seria um contrassenso que, sem o primeiro título de condenação, a sentença, houvesse motivo para manutenção do cárcere. E, depois, com a definição da culpa (ou pelo menos a primeira definição rumo à culpa), tivessem o direito de deixar a prisão.

Assim, já se decidiu: "Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. (...) Direito de apelar em liberdade. Réu que permaneceu custodiado ao longo do processo. Prisão preventiva. Fundamentação. I - O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. (Precedentes do STJ e do STF). II - A exigência da prisão provisória para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. (Súmula n. 09 do STJ). (...) III - Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantir ao paciente a revogação da prisão cautela (Precedentes). Writ denegado" (HC 62882/RS; Ministro Felix Fischer, j. 07/11/2006, DJ 12.02.2007, p.285).

O presente caso não comporta aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois, com a prisão provisória, ainda não alcançaram o tempo que lhes permitiria a progressão de regime.

Ante ao exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, o que faço para condenar os réus THALES ALECKSANDER FERREIRA MENDES e NATAN LUIS ASSIS DA COSTA como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo a unidade.

Cada dia-multa deverá ser calculado sobre um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato e devidamente corrigida, nos termos do art. 49, do Código Penal.

Como exposto acima, sem direito a recurso em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontram.

Condeno-os ainda no pagamento das custas, no valor de 100 UFESPs, observando-se, contudo, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fl. 141).

Comprovado o tráfico de drogas, decreto o perdimento do dinheiro e celular apreendidos, em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, não foi comprovada a origem lícita dos bens apreendidos.

Agora, com a sentença decretada, estando o laudo definitivo da droga nos autos, determino a destruição da contraprova armazenada, servindo esta como ofício.

Por fim, após o trânsito em julgado desta sentença, comunique-se à Justiça Eleitoral a suspensão dos direitos políticos dos réus (art. 15, inc. III, da Constituição Federal).

P. C. I. C.

São José do Rio Preto, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA